

1508999-14.2021.8.26.0071

Classe: Procedimento Especial da Lei Antitóxicos

Assunto: Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Magistrado: Cláudio Augusto Saad Abujamra

Comarca: Bauru

Foro: Foro de Bauru

Vara: 3ª Vara Criminal

Data de Disponibilização: 11/10/2022

... outro lado, não há dúvida de que ele estava praticando tráfico, haja vista que trazia no estômago quantidade razoável de drogas.

Certamente, ninguém se arriscaria a assim agir para carregar entorpecente para mero deleite.

Com efeito, não se desconhece o risco de ser preso numa situação tal sob suspeita de tráfico, e nem o risco para a saúde humana derivado da ...

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO

COMARCA de Bauru

Foro de Bauru

3ª Vara Criminal

Rua Afonso Pena, 5-40, Bauru-SP - cep 17060-900

Horário de Atendimento ao Público: das 13h00min às 17h00min

1508999-14.2021.8.26.0071 - lauda

SENTENÇA

Processo Digital nº:

1508999-14.2021.8.26.0071

Classe - Assunto:

Procedimento Especial da Lei Antitóxicos - Tráfico de Drogas e Condutas Afins

Documento de Origem:

Inquérito Policial, Inquérito Policial, Boletim de Ocorrência, Portaria -

2267525/2021 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 15336810 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-

DEINTER 4, 171/21/404 - 2ª ENTORPECENTES-DEIC-DEINTER 4, 2267525 - 2ª ENTORPECENTES-

DEIC-DEINTER 4

Autor:

Justiça Pública

Réu:

GABRIEL CARNEIRO DE LIMA

Juiz(a) de Direito: Dr(a). Cláudio Augusto Saad Abujamra

Vistos.

GABRIEL CARNEIRO DE LIMA foi dado como incurso nas penas do art. 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11.343/2006 e, art. 349-A, do Código Penal, todos na forma do art. 69, caput do Código Penal, porque, no dia 05 de janeiro de 2021, por volta das 17h00, no CPP I - Dr. Alberto Brocchieri, nesta cidade, trazia consigo, para fins de tráfico, 76,74 gramas de maconha, 5,48 gramas de cocaína e 1,11 gramas de 5-Fluoro-MDMB-PICA, drogas que determinam dependência física e psíquica, sem autorização ou em desacordo com determinação legal e regulamentar, bem como, nas mesmas circunstâncias de tempo e local, promoveu a entrada de quatro aparelhos celulares no referido estabelecimento prisional.

Notificado (fls. 117), o réu apresentou a defesa preliminar de fls. 122/123. A denúncia foi recebida por despacho datado de 15 de dezembro de 2.021 (fls. 125/127).

Em audiência, foram ouvidas testemunhas e o réu foi interrogado (fls. 156/180).

Em alegações finais, o representante do Ministério Público pediu a procedência da ação penal, nos termos da denúncia (fls. 194/197).

Já a defesa técnica se manifestou a fls. 202/209, alegando que: 1)- a confissão restou isolada; 2)- o agente João Luiz declarou que a maioria dos detentos cometem esse delito por conta de dívidas ou necessidade de fazer dinheiro; 3)- o agente Lupércio afirmou que a maioria dos presos praticam esse crime por conta de dívidas de drogas; 4)- não foram feitas diligências na cela ou nos pertences do réu à procura de mais drogas ou apetrechos para fracionar ou embalar o material; 5)- estando o acusado preso, não tinha como produzir prova da coação que estava sofrendo, pois não tinha instrumento tecnológico para gravação da ameaça, ou, se indicasse o traficante, morreria; 6)- se um preso acusa outro, passa a ser repellido pela massa carcerária, passa a viver sob risco e é colocado no "seguro"; 7)- o artigo 386 do Código de Processo Penal não exige prova plena da causa de exclusão de culpabilidade; 8)- quanto ao crime do artigo 349-A do Código Penal, não há prova da materialidade, pois os celulares não foram periciados e, caso os aparelhos não estivessem funcionando, ter-se-ia a hipótese de crime impossível; 9)- quanto ao crime do artigo 349-A do Código Penal, também deve-se cogitar de coação moral irresistível; 10)- a hipótese é de crime impossível, pois os presos são submetidos a revista antes de entrarem na unidade, de modo que os celulares seriam descobertos; 11)- não pode haver cúmulo material entre crimes apenados com reclusão e detenção. Pediu a absolvição e, alternativamente, o reconhecimento da atenuante da confissão, o reconhecimento da tentativa em relação ao crime do artigo 349-A do Código Penal, o afastamento do concurso material, a fixação do regime inicial aberto para o crime apenado com detenção e o semiaberto para o apenado com reclusão.

É o relatório. Passo a decidir.

A materialidade dos crimes está demonstrada pelo boletim de ocorrência de fls.

07/08, pelo auto de apreensão de fls. 09/10 e pelos laudos periciais de fls. 14/19 (trinta e duas porções de maconha com peso de 76,74 gramas, duas porções de cocaína com peso de 5,48 gramas e uma porção de 5-Fluoro-MDMB-PICA com peso de 1,11 gramas) e de fls. 20/27 (exame de quatro telefones celulares).

A autoria e o intuito de traficância derivam da prova oral e das circunstâncias do caso e devem ser atribuídos ao acusado.

Em juízo, a testemunha Lupércio Teixeira Correia, agente de segurança penitenciária, afirmou que os presos estavam sendo submetidos ao body scanner ao retornarem da saída temporária. Quando o réu passou pelo aparelho, foi verificado que ele tinha algo ilícito no interior de seu abdome. Indagado, o acusado confessou que havia engolido quatro mini-celulares, dinheiro, maconha e cocaína. Viu o material por ele expelido. Na maior parte das vezes, os detentos levam objetos ilícitos para dentro da unidade a fim de quitar dívidas de droga (fls. 167/169).

A testemunha João Luiz da Silva, também agente de segurança penitenciária, relatou que, na ocasião, os detentos retornavam de saída temporária do final de ano. Estava realizando a recolha dos sentenciados. Eles foram submetidos ao scanner e o acusado foi flagrado com objetos ilícitos no estômago. Ele havia inserido no corpo quatro mini celulares, dinheiro, dois invólucros de cocaína e entre trinta e trinta e dois invólucros de maconha, além de algumas fitas que pareciam ser de droga sintética conhecida como "K4". Não se recorda da explicação do acusado, pois são muitos casos parecidos. Lembra-se que ele "já assumiu e provocou vômito para expelir". Alguns presos adentram com drogas no presídio em razão de dívidas, e outros, para ganhar algum dinheiro (fls. 171/173).

Interrogado em juízo, o réu declarou que tinha dívida. Os "meninos" lhe pediram para engolir os materiais, a fim de que a dívida fosse paga. Era o único jeito de pagar o débito, pois não tinha dinheiro. Não fazia trabalho externo. Como era novo na unidade prisional e o momento era de início de pandemia, não tinha local para trabalhar. A dívida era de vinte e cinco mil reais e foi contraída na rua. Era

usuário e dava muito trabalho. Estava na Penitenciária I de Bauru há quatro meses. Antes, estava preso em Bernardino de Campos (fls. 175/179). Diante de tal conjunto probatório, impõe-se a condenação do acusado nos termos da denúncia, não merecendo guarida as teses expostas nas alegações finais produzidas em sua defesa.

O fato e sua autoria estão bem demonstrados.

Com efeito, o réu confessou ao menos que trazia consigo, em seu abdômen, os objetos apreendidos.

Ele admitiu o fato em juízo, livre de qualquer forma de pressão ou coação.

Sobre a suficiência da confissão judicial enquanto elemento de prova, verifique-se o seguinte julgado:

"Prova. Confissão judicial. Único elemento de prova a embasar a condenação.

Admissibilidade. A confissão judicial tem valor absoluto e, ainda que seja o único elemento de prova, serve como base à condenação, só podendo ser recusada em circunstâncias especialíssimas, ou seja, naquela em que lhe evidencie a insinceridade, ou quanto tiver prova veemente em contrário." (TJSP, RT 744/573).

De qualquer forma, a confissão não está isolada no conjunto probatório.

Ao contrário, a prática dos delitos foi confirmada pelo depoimentos de dois agentes de segurança penitenciária, os quais flagraram o réu com os objetos ilícitos em seu estômago quando da revista no momento do retorno de saída temporária.

As afirmações dos agentes se afiguram firmes, coerentes e comedidas ou sem tendências para o exagero, merecendo, por isso, serem tidas como expressão da verdade.

De resto, a jurisprudência já assentou a validade da prova consistente em depoimentos de agentes públicos encarregados da manutenção da ordem.

À propósito:

"Não se pode presumir em policiais ouvidos como testemunha a intenção de incriminar falsamente o acusado da prática de crime contra a saúde pública na modalidade de tráfico de entorpecente por asseverarem que a substância tóxica foi encontrada em poder daquele. A presunção, ao contrário, é de idoneidade dessas testemunhas, ainda mais quando seus depoimentos são seguros, precisos e uniformes desde a fase inquisitorial e não há qualquer razão concreta de suspeição." (RT 610/369).

Em igual sentido:

"O valor do depoimento testemunhal de servidores policiais especialmente quando prestado em juízo, sob a garantia do contraditório reveste-se de inquestionável eficácia probatória, não se podendo desqualificá-la pelo só fato de emanar de agentes estatais, incumbidos, por dever de ofício, da repressão penal." (STF, D.J. 18/10/96, Habeas Corpus n. 73.518-5 São Paulo, rel. Min. Celso de Mello).

E, especificamente em relação a depoimentos de agentes de segurança penitenciários:

"(...) o reconhecimento da prática de falta grave baseou-se especialmente nos depoimentos de dois agentes penitenciários que gozam de fé pública -, os quais narraram de forma uníssona e harmônica a utilização, pelo paciente, de telefone celular em unidade prisional. Por isso, a ausência de apreensão do aparelho, por si só, não pode afastar tal conclusão." (HC 254.312/Sp, rel. Ministra Laurita Vaz, Quinta Turma, julgado em 06/08/2013, DJE 13/08/2013). (em TJSP, Apelação n. 0029345-41.2013.8.26.0071, rel. Silmar Fernandes, j. 13/11/2015).

Logo, a prova aponta, de modo estreme de dúvidas, que o réu trazia em seu estômago, no momento da revista, telefones celulares e drogas.

Por outro lado, não há dúvida de que ele estava praticando tráfico, haja vista que trazia no estômago quantidade razoável de drogas.

Certamente, ninguém se arriscaria a assim agir para carregar entorpecente para mero deleite.

Com efeito, não se desconhece o risco de ser preso numa situação tal sob suspeita de tráfico, e nem o risco para a saúde humana derivado da circunstância de se trazer droga dentro da cavidade abdominal.

Ademais, o art. 33, caput, da Lei Antidrogas, define crime de conteúdo múltiplo e de perigo abstrato.

Dessa forma, basta que o agente incorra em qualquer dos verbos ali descritos, desde que sem a finalidade de consumo da droga, para que o delito de tráfico reste

caracterizado.

Não é indispensável, assim, que o agente seja flagrado em pleno ato de mercancia de droga, sendo suficiente que a traga consigo (conforme descrito na denúncia e comprovado na instrução).

Sob tal prisma, já é irrelevante a alegação de que a cela onde estava o réu e seus pertences não foram revistados com a finalidade de se encontrar outras drogas ou apetrechos comumente relacionados à traficância.

Prosseguindo, a alegação de que houve coação moral irresistível não restou minimamente comprovada.

A mera alegação de estar sendo coagido, sem outras provas para corroborar sua existência, não é suficiente para formar convicção a respeito.

Conforme dispõe o artigo 156 do Código de Processo Penal, o ônus de provar cabia à defesa, e dele ela não se desincumbiu.

Neste sentido:

"APELAÇÃO CRIMINAL. RECURSO DE DEFESA E DO MINISTÉRIO PÚBLICO. Art. 33 da Lei nº 11.343/06. ABSOLVIÇÃO PELA COAÇÃO MORAL IRRESISTÍVEL. IMPOSSIBILIDADE. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. REDUÇÃO DA PENA-BASE. IMPOSSIBILIDADE. 1. A coação moral irresistível deve ser comprovada por quem a alega, nos termos do art. 156 do CPP, pois incumbe à defesa o ônus de provar eventuais fatos impeditivos ou extintivos da pretensão punitiva, tais como a excludente de culpabilidade alegada. A mera alegação não é suficiente para comprovar. (Apelação 0000049-06.2016.8.08.0059 - TJ ES - 1ª Câmara Criminal - Relator: Willian Silva).

É certo que o agente Lupércio declarou que, na maior parte das vezes, os detentos levam objetos ilícitos para dentro da unidade a fim de quitar dívidas de droga, ao passo que, de acordo com seu colega João Luiz, alguns presos adentram com entorpecentes no presídio em razão de dívidas, e outros, para ganhar algum dinheiro.

Não menos certo, porém, é que os agentes não esclareceram como tomaram conhecimento de que presos entram com drogas na unidade prisional para quitar dívidas, de modo que não se pode descartar que fizeram tal afirmação apenas com base no relato dos próprios detentos.

Ademais, a afirmação é tão somente no sentido de que a conduta é cometida para pagar dívidas, e não de que ocorre, paralelamente, coação moral irresistível (são coisas bem diversas).

No caso dos autos, cumpre destacar que o réu declarou ter contraído uma dívida referente a drogas no valor de vinte e cinco mil reais quando estava na "rua". No entanto, não é concebível considerar quitada uma dívida nesse elevado montante apenas com o serviço de transporte, para dentro da unidade prisional, de quatro telefones celulares e quantidade de drogas não muito elevada (no total, cerca de 84 gramas).

Afinal, a comercialização de tais itens, no interior do presídio, não renderia nem a metade do valor da dívida.

Não bastasse, segundo a certidão de fls. 190, o acusado já estava preso desde 30/01/2016.

Não é razoável crer que ele tenha permanecido por tanto tempo no sistema prisional e somente tenha sido coagido a pagar sua dívida (contraída na "rua", ou seja, quando estava solto) na data do fato, isto é, em 05 de janeiro de 2021.

Destarte, a alegação de coação moral irresistível é de causar espécie, a evidenciar que o réu não disse a verdade.

Não se desconhece que o inciso VI do artigo 386 do Código de Processo Penal não exige prova plena da existência de circunstância que isente o réu de pena.

No entanto, deve haver, segundo o mesmo dispositivo legal, ao menos "fundada dúvida sobre sua existência".

Considerando os argumentos e circunstâncias expostos, sequer há que se falar na presença de tal fundada dúvida.

Tampouco há que se pensar em crime impossível, sob argumento de que, como todos os detentos são revistados ao entrar ou sair da unidade prisional, o réu não conseguiria introduzir os aparelhos ou a droga no presídio.

Na verdade, o acusado teria conseguido seu intento se contasse com a conivência ou

negligência dos agentes de segurança penitenciária.

Aliás, a própria experiência contradiz o argumento da defesa, pois se sabe que, constantemente, são encontrados aparelhos da espécie e entorpecentes no interior de unidades prisionais.

Ainda, em caso análogo, assim se orienta a jurisprudência:

"Apelação. Tráfico de drogas. Pedido de absolvição por fragilidade probatória ou, quando não, pelo reconhecimento de crime impossível, ante a absoluta ineficácia do meio empregado pela ré para transportar o entorpecente para o interior do presídio, tendo em vista o procedimento de revista ao qual seria submetida. Não acolhimento. Autoria e materialidade comprovadas. Existência de amplo conjunto probatório suficiente para sustentar a condenação. Eficácia, ademais, do meio empregado pela ré para a prática do tráfico. Reincidência específica, não reconhecida em primeiro grau, bem comprovada nos autos. Recurso ministerial provido, para aumentar as penas, e improvido o apelo defensivo." (TJSP, Apelação n. 0076838-45.2010.8.26.0224, rel. Sérgio Coelho, j. 29/11/2012).

Especificamente no tocante ao crime do artigo 349-A do Código Penal, cabe acrescentar que não se pode acolher a tese de inexistência de materialidade.

Ao contrário do que sustenta a defesa, houve, sim, perícia nos aparelhos apreendidos, constatando-se que se tratava de celulares em regular estado de conservação, de modo que, se eventualmente não estavam funcionando, podiam via a funcionar desde que se lhes acoplassem baterias (fls. 20/27).

Ainda em relação ao delito do artigo 349-A do Código Penal, não há que se falar em mera tentativa.

O tipo penal faz referência em "ingressar (...) em estabelecimento prisional".

O local onde se realizam as revistas e onde, inclusive, instalado o aparelho de scanner corporal já se situa no estabelecimento prisional.

Trata-se, portanto, de hipótese de crime consumado.

No mais, não há que se cogitar de afastamento da causa de aumento prevista no art. 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006, apenas em razão do fato de o autor do delito ser detento, pois a lei não faz distinção.

Nesse sentido:

"De igual modo, é caso de manter o aumento decorrente do fato de ter sido praticado o delito nas dependências de estabelecimento prisional, incidindo, na espécie, a causa de aumento prevista no artigo 40, inciso III, da Lei n. 11.343/2006.

Ressalte-se que referida majorante não deixa de incidir quando o agente é detento do presídio, porquanto a lei não traz qualquer particularização a respeito da característica do autor do crime. O colendo Superior Tribunal de Justiça já havia assentado entendimento de que a causa de aumento prevista no inciso IV do artigo 18 da antiga Lei n. 6.368/76 era aplicável ao presidiário que comete o crime de tráfico de entorpecentes nas dependências do estabelecimento penal: 'Para incidência da causa de aumento prevista no artigo 18, inciso IV, da Lei n. 6.368/76, in casu, delito cometido dentro do estabelecimento penal, pouco importa que o crime tenha sido praticado por agente que esteja em liberdade ou por preso. (Precedentes do Pretório Excelso e do STJ)'. (REsp 662779/MG; Recurso Especial 2004/0078379-7, Ministro Felix Fischer, Quinta Turma)." (em TJSP, Apelação n. 0000339-05.2010.8.26.0326, Rel. Borges Pereira, j. 04/12/2012).

Em suma, deve o réu ser condenado nos termos da denúncia.

Passa-se à aplicação da pena.

Fixam-se as penas base no mínimo legal, ou seja, cinco anos de reclusão, mais quinhentos dias-multa, para o crime de tráfico, e três meses de detenção, para o crime previsto no art. 349-A do Código Penal.

O réu é reincidente (fls. 190 – art. 157, §2º, incisos I e II, do Código Penal; e fls. 191- art. 157, §2º, inciso II, do Código Penal).

No entanto, confessou ao menos que trazia consigo a droga e os telefones celulares, conforme reconhecido tanto pela acusação como pela defesa.

Entende o juízo que a atenuante da confissão, por dizer respeito à personalidade do agente, prepondera sobre a agravante da reincidência.

Nesse sentido:

"Por envolver a personalidade dos agentes, a atenuante da confissão espontânea é

igualmente preponderante e deve ser compensada com a agravante da reincidência." (HC n. 288.910/SP, 6a Turma, relatora Ministra Maria Thereza de Assis Moura, j. Em 21/10/2014) (em TJSP, Apelação n. 0020654-38.2013.8.26.0071, j. 21/05/2015). No caso concreto, no entanto, não se pode determinar pura e simplesmente a compensação integral entre a atenuante da confissão e a reincidência, pois, como visto, dão duas as condenações anteriores a ensejar a agravante em tela. Nessa ótica, o melhor a fazer é desconsiderar apenas parcialmente o efeito das condenações pretéritas.

Nesse sentido:

"... não há como se operar a compensação integral ante a constatação de múltiplas reincidências. A melhor solução para a hipótese, a fim de não desprestigiar a confissão proporcionada pelos réus, é desconsiderar uma das condenações que caracterizam a reincidência e acrescer à pena patamar de aumento somente pelas condenações restantes." (TJSP, Apelação n. 0023777-06.2010.8.26.0344, rel. Salles Abreu, j. 28/02/2012).

Sendo assim, na segunda fase de aplicação da pena, considerando a reincidência e sua parcial compensação com a atenuante da confissão, elevam-se as penas na proporção de apenas um sexto, resultando em cinco anos e dez meses de reclusão, mais quinhentos e oitenta e três dias-multa para o delito de tráfico, e em três meses e quinze dias de detenção, para a conduta do art. 349-A do Código Penal. Deve incidir a causa de aumento de pena do artigo 40, inciso III, da Lei 11.343/2006, quanto ao delito de tráfico, majorando-se a pena em um sexto, resultando, portanto, em seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, mais seiscentos e oitenta dias-multa.

Não havendo outras modificadoras, tais penas são as definitivas.

Não é possível a aplicação do concurso material de crimes, tendo em vista tratar-se de delitos punidos com penas de espécies diversas (detenção e reclusão).

Isto porque, na forma do artigo 76 do Código Penal, "no concurso de crimes, executar-se-á primeiramente a pena mais grave".

Outrossim, segundo o artigo 681 do Código de Processo Penal, "se impostas cumulativamente penas privativas de liberdade, será executada primeiro a de reclusão, depois a de detenção e, por último a de prisão simples".

Afasta-se, pois, a regra do concurso material.

Ante o montante das penas aplicadas e a reincidência (ensejada por duas condenações anteriores por crimes de roubo), o regime inicial de cumprimento de pena será o fechado para o tráfico e o semiaberto para o crime do artigo 349-A do Código Penal. O valor do dia-multa será calculado no piso mínimo.

Ante o exposto, JULGO PROCEDENTE a presente ação, para condenar o réu Gabriel Carneiro de Lima: 1)- como incurso nas penas do artigo 33, caput, combinado com artigo 40, inciso III, ambos da Lei n. 11343/2006, a cumprir seis anos, nove meses e vinte dias de reclusão, em regime inicial fechado, e a pagar seiscentos e oitenta dias-multa, calculado o valor do dia-multa no piso mínimo e, 2)- como incurso nas penas do artigo 349-A do Código Penal, a cumprir três meses e quinze dias de detenção, em regime inicial semiaberto.

Oportunamente, anote-se a condenação no sistema informatizado.

Declaro a perda em favor da União, e a reversão ao Funad, do numerário em dinheiro apreendido nos autos, nos termos do art. 91, II, "b", do Código Penal, e art. 63, § 1º, da Lei n. 11.343/2006.

Quanto aos demais bens apreendidos, são daqueles cujas posses, por si sós, não configuram fato ilícito. Dessa forma, aguarde-se por noventa dias a contar do trânsito em julgado eventual pedido de restituição. Na inércia, os bens deverão ser doados ou inutilizados, nos termos das Normas de Serviço da Corregedoria Geral da Justiça do TJSP.

P.R.I.

Bauru, 11 de outubro de 2022.

DOCUMENTO ASSINADO DIGITALMENTE NOS TERMOS DA LEI 11.419/2006, CONFORME IMPRESSÃO À MARGEM DIREITA